

刑法
No127

共通問題 H23-10

(配点：3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、乙を毒殺する目的で毒入り菓子をお歳暮として郵送するため、郵便局の窓口でその菓子を包んだ小包の郵送を申し込んだが、誤って実際には存在しない住所を宛先として記載したために同小包はどこにも配達されずに甲宅に送り返された。この場合、甲には殺人未遂罪が成立する。
- イ. 甲は、自己が居住する建物に付した火災保険の保険金を保険会社からだまし取る目的で同建物に放火したが、保険金を請求するに至らなかった。この場合、甲には詐欺未遂罪は成立しない。
- ウ. 甲は、乙の住居内に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金目の物を探したが、見付けることができないうちに乙に発見された。甲は、逮捕を免れるため、乙に対して包丁を示して脅迫し、屋外に逃走したが、通報により駆けつけた警察官に現場付近で逮捕された。この場合、甲には事後強盗未遂罪が成立する。
- エ. 甲は、勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ、逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが、いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず、逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合、甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
- オ. 甲は、他人が居住する建物に放火することを企て、30分後に発火して導火材を経て同建物に火が燃え移るように設定した時限発火装置を同建物に設置したが、設定した時刻が到来する前に発覚して同装置の発火に至らなかった。この場合、甲には現住建造物等放火未遂罪は成立しない。

No127	実行の着手						正答率
共通H23-10	正解	ア 2	イ 1	ウ 1	エ 2	オ 2	60%

ア 誤っている

大判大 7.11.16 (百選 I 65 事件) は、毒を混入した白砂糖を郵送小包で送付し、相手方はこれを受領したが異常に気づき食べなかったという事案で、相手方がこれを受領したときに、殺人の実行の着手があるとしている。受領したときに、同人又はその家族の食用し得べき状態の下に置かれたことになるからである。本記述では、毒入り菓子は乙方だけでなくどこにも配達されていないから、実行の着手はなく、甲に殺人未遂罪 (203 条、199 条) は成立しない。

イ 正しい

大判昭 7.6.15 は、保険金騙取の目的をもって家屋に放火して焼損したとしても、未だ保険会社に対して保険料支払の請求をした事情がないため、未だ詐欺の実行の着手があったということができないとして、詐欺未遂罪は成立しないとしている。理由として、判例は、放火行為は詐欺罪の準備行為にすぎないことを挙げている。甲は、まだ保険金を請求するに至っていないから、詐欺罪の実行の着手はなく、詐欺未遂罪は成立しない。

ウ 正しい

判例は、財物を取り返されまいとして暴行・脅迫を加える場合の窃盗犯人は、すでに被害者から財物を奪取し終えた窃盗既遂犯であることを要するが、その他の目的をもって暴行・脅迫を加える場合の窃盗犯人は、窃盗既遂犯であると未遂犯であると問わないとしている (大判昭 7.12.12)。本記述における甲は、乙宅に侵入してタンスの引き出しを開けるなど、他人の財物に対する事実上の支配を侵すについて密接な行為をしているので、窃盗罪の実行の着手が認められ、窃盗未遂 (243 条、235 条) が成立する (大判昭 9.10.19 参照)。よって、甲は「窃盗」にあたることになる。次に、本記述では甲は乙に脅迫を加えることで、屋外に逃走することができており、乙による逮捕を免れるという目的を達成していることから、事後強盗既遂罪が成立するのではない。事後強盗罪の既遂・未遂の判断基準が問題となる。判例は、「窃盗未遂犯人による準強盗行為の場合は、準強盗の未遂を以って問擬すべきものである」としている (最判昭 24.7.9)。その理由として、判例は、窃盗未遂犯人による準強盗は、財物を得なかった点において、あたかも強盗の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものであるということを挙げている。よって、本記述では、甲は窃盗未遂犯であることから、事後強盗未遂罪が成立することになる。

エ 誤っている

最判昭 54.12.25 は、加重逃走罪のうち拘禁場又は械具損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、加重逃走罪の実行の着手があるとする。判例に賛成する学説は、理由として、逃走の目的をもって看守者の実力的支配を基礎付けている人的物的設備に対し侵害を加えることは、それが逃走との関係であまりに間接的であるような場合を別として、ほとんどの場合に、とりもなおさず看守者の実力的支配から離脱しようとする行為であるととらえることができるということを挙げている。

オ 誤っている

装置の設置により高度の客観的危険状態が発生すると認められる場合には、実行の着手が認められると解されている。本記述では、30 分後に発火して、導火材を経て建物に火が燃え移るように装置が設定されているので、放火の高度の客観的危険状態が生じているといえる。よって、甲に現住建造物等放火罪の実行の着手が認められ、現住建造物等放火未遂罪が成立する。